

1500642-76.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... não se pode olvidar que em pontos de tráfico também são encontrados usuários. E ainda que se diga que o réu informalmente confessou o tráfico, tal informação deve ser recebida com reservas, porque não se mostra razoável que alguém surpreendido com pequena quantidade de droga acabe confessando crime mais grave. Além disso, se houve, a confissão informal deve ser desprezada, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500642-76.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2117632/2022 -

DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 24662436 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2117632 - 02º

D.P. PIRACICABA, 2117632/2022 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK FERNANDO MAGDALENO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Contr. nº 2022/000510

Aos 11 de julho de 2022, às 14:30 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Antonio Carlos Perez Antunes da Silva foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu PATRICK FERNANDO MAGDALENO DE OLIVEIRA (preso CDP local). Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PM JOAO GUILHERME ANDRIOLI e PM GUSTAVO PHATRICY NICOLAU SILVA

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (Pms João e Gustavo) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

Dada a palavra ao Dr. Promotor foi dito que desistia da oitiva da testemunha(s) PM Gustavo, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a).

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). PATRICK FERNANDO MAGDALENO DE OLIVEIRA, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois no dia 01 de maio de 2022, por volta das 10h42, na Rua Jamaica, nº 29, Bairro Agua Branca, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 4,3g de cocaína, distribuídos em 32 eppendorfs1, substância entorpecente a qual determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 69/72). O réu foi notificado, a denúncia foi recebida e durante a instrução prestaram depoimento as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o réu interrogado. A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade delitiva foi confirmada nos autos pelo auto de exibição e apreensão a fl. 11, foto a fl. 12 e laudo pericial a fls. 105/107. Da mesma forma, comprovada a autoria delitiva. De fato, o policial João relatou, na fase informativa (fls. 02), que EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO ÁGUA BRANCA, LOCAL CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS, FOI AVISTADO UM INDIVÍDUO DE CAMISA BRANCA E BERMUDA COLORIDA, QUE AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL MUDOU REPENTINAMENTE DE DIREÇÃO. O POLICIAL AFIRMA QUE DESCONFIU DESSA ATITUDE E RESOLVEU REALIZAR ABORDAGEM PARA AVERIGUAÇÃO. NA TENTATIVA DE ABORDAGEM O INDIVÍDUO EM QUESTÃO, ORA INDICIADO, TENTOU SE EVADIR PARA UMA PRAÇA, ACELERANDO O PASSO, SENDO ABORDADO IMEDIATAMENTE. SEGUNDO O POLICIAL, REALIZADA BUSCA PESSOAL, FOI ENCONTRADO EM SEU BOLSO 2 EMPENDORFES NA COR VERDE CONTENDO COCAÍNA, 55 REAIS E UM TELEFONE CELULAR. INDAGADO DE MANEIRA INFORMAL, O INDICIADO CONFESSOU QUE ESTAVA NA PRÁTICA DE VENDAS DE DROGAS, E APONTOU O LOCAL ONDE ESTARIA O RESTANTE DAS SUBSTÂNCIAS. O POLICIAL AFIRMA QUE NO LOCAL APONTADO PELO INDICIADO, UMA ÁRVORE PRÓXIMA DO LOCAL DA ABORDAGEM, LOCALIZOU O RESTANTE DAS DROGAS". Em juízo confirmou sua versão. Acrescentou que o acusado ao visualizar a viatura, virou-se no sentido contrário. O local é ponto de venda de drogas. O local onde foram encontradas outras drogas idênticas foi indicado pelo réu, a cerca de 10, 15 metros. Disse que havia mais pessoas na rua, mas ninguém correu e ninguém em atitude suspeita nas proximidades de onde estavam armazenadas as drogas. O PM Gustavo ratificou as informações prestadas pelo seu companheiro de farda. Acrescentou que já havia prendido o acusado por furto em outra ocasião. Assim, a grande quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, juntamente com a apreensão de dinheiro, somadas às circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam o comércio ilícito. De fato, o réu teve atitude suspeita em local de venda de drogas e foi abordado. Na sua posse, foram encontrados entorpecentes e dinheiro. Ele, ademais, indicou o local onde estavam armazenadas drogas. Neste panorama, devidamente demonstrados os fatos descritos na denúncia, restando isolada nos autos a versão apresentada pelo réu. Não se alegue a ocorrência de nulidade na abordagem do réu, visto que ele estava em ponto de tráfico de drogas e mostrou atitude suspeita, mudando de direção ao ver a viatura e tentando sair da vista dos policiais, razão pela qual plenamente justificável a abordagem. Diante do acima exposto, requer-se a procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da incoativa. Na aplicação da pena há que se observar que o réu não ostenta antecedentes, mas possui diversas passagens pela Vara da infância e Juventude, com cumprimento de medida socioeducativa pela prática do tráfico de drogas (certidões a fls. 36/37 e 82/85, 88/90, 159/162) e foi beneficiado com a liberdade provisória dia 21 de fevereiro de 2022 pela prática do crime de furto (certidões a fls. 34/35), razão pela qual restou claro que se dedica a atividades criminosas e não faz jus à causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Outrossim, o regime inicial de cumprimento de pena

deverá ser o fechado, de acordo com as normas legais, e porque o crime de tráfico merece um grau maior de reprovabilidade, pois causa sérias consequências no meio social, notadamente no meio familiar, fomentando o uso indiscriminado de entorpecentes e, conseqüentemente, a prática de outros crimes pelo usuário, como pequenos furtos e roubos, os quais são praticados com o escopo de sustentar o seu vício. Incabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que reconhecida a impossibilidade de ser aplicado o redutor pelas razões antes mencionadas, a pena suplantará 04 anos, bem como o crime em questão é de elevada gravidade, o que demonstra não ser a medida socialmente adequada. Por fim, uma vez que comprovado que o dinheiro apreendido era oriundo do comércio de drogas, o Órgão Ministerial requer que seja decretada sua perda.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). PATRICK FERNANDO MAGDALENO DE OLIVEIRA vem processado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme os fatos narrados na inicial acusatória. Após o recebimento da denúncia, a ação penal teve seu regular trâmite e a instrução foi encerrada na presente audiência. Em suas alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Ocorre, contudo, que a pretensão ministerial não encontra guarida, devendo a ação penal ser julgada improcedente. Com efeito, segundo consta, o acusado foi preso em flagrante após sofrer abordagem dos policiais militares que suspeitaram de sua conduta. Ocorre, porém, que ao explicarem os motivos que os levaram a suspeitar do réu, os policiais militares simplesmente disseram que ele teria andado no sentido oposto ao da viatura, após visualizá-la. E isso evidencia a ilegalidade da medida tomada pelos policiais. De fato, como cediço, a revista pessoal é medida excepcional que só pode ser justificada diante da existência de fundada razão de que a pessoa abordada esteja em posse de arma proibida, objeto ou papéis que constituam o corpo de delito (art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal). Ou seja, para haver a busca pessoal, deve haver “fundada suspeita” da ocultação de algum objeto ligado ao crime. Mas isso não aconteceu. Na verdade, antes da abordagem, não existia qualquer dado concreto – e objetivamente aferível – de que o réu estaria praticando o crime de tráfico de entorpecente (ou qualquer outro delito). A abordagem dele se deu mediante critério meramente subjetivo, o que não é suficiente para autorizar a busca pessoal, sob pena de violação ao direito constitucional à intimidade (art. 5º, X, CF). Aliás, em caso semelhante, em que a pessoa foi abordada porque “fugiu” da viatura policial, o C. Superior Tribunal de Justiça entendeu que a revista pessoal foi ilícita: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes”. (HC 625.819/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021). Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça também entendeu como ilegal a busca pessoal efetivada após um suposto “nervosismo” da pessoa abordada: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. REVISTA PESSOAL E INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao

ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio . 2. Também há a compreensão neste Superior Tribunal de que se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 3. No caso concreto, o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos policiais não indicam a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem, as buscas foram motivadas no "nervosismo" apresentado pelo acusado. Não ficou consignado em sentença nem no acórdão impugnado que os policiais haviam presenciado o paciente vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse a abordagem pessoal. 4. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. (HC 659.689/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). E, como se observa, o entendimento do Tribunal Superior é no sentido que o fato do crime em questão (tráfico de drogas) ser classificado como permanente não importa, pois a suposta infração penal só veio à tona depois de uma abordagem feita a partir de mera conjectura. Portanto, a conduta dos agentes policiais que realizaram a abordagem/revista pessoal no acusado sem a existência de justa causa deve ser considerada ilegal. E uma vez reconhecida a ilicitude, todos os demais elementos derivados da busca igualmente devem ser tidos como ilegais, o que deve resultar na absolvição do réu, por ausência de provas válidas. Afinal, é evidente o nexo existente entre a revista pessoal e todos os elementos que deram suporte ao início da ação penal. Excluindo-se a busca ilegal, não haveria prisão, oferecimento da denúncia e início da ação penal. Logo, diante do todo exposto, requer-se o reconhecimento da ilicitude da ação policial e a consequente absolvição do acusado, nos termos do art. 386, II ou VII, do Código de Processo Penal, pela absoluta falta de qualquer prova válida. Caso, no entanto, seja superada a questão sobre a invalidade das provas, a Defesa pugna pela absolvição do acusado em decorrência da fragilidade probatória. Isso porque a prova que o incrimina se resume aos depoimentos dos policiais que o prenderam em flagrante. E nessa condição, evidentemente que seus testemunhos não podem ser considerados como totalmente isentos, pois há uma necessidade de justificarem seus atos. Não se quer dizer que eles mentiram e que incriminaram o réu injustamente. Mas apenas que seus depoimentos não possuem a isenção necessária para, por si só, sustentarem uma condenação . Além disso, existindo apenas a prova oral, não se pode dar preferência ao depoimento dos servidores municipais em detrimento do interrogatório do acusado, o qual tem em seu favor a presunção de inocência. Assim, mostrando-se frágil o conjunto probatório, requer-se a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. De maneira subsidiária, a Defesa pugna pela desclassificação da conduta do acusado para a prevista no art. 28, da Lei de Drogas. De fato, ainda que acolhida integralmente a versão dos milicianos, percebe-se que com o acusado só foram localizadas duas porções, bem como cinquenta e cinco reais. As demais substâncias foram encontradas em local diverso, junto a uma árvore. Logo, estando em plena via pública, poderiam pertencer a qualquer pessoa. Além disso, não se pode olvidar que em pontos de tráfico também são encontrados usuários. E ainda que se diga que o réu informalmente confessou o tráfico, tal informação deve ser recebida com reservas, porque não se mostra razoável que alguém surpreendido com pequena quantidade de droga acabe confessando crime mais grave. Além disso, se houve, a confissão informal deve ser desprezada, pois evidentemente foi colhida sem qualquer observância ao direito constitucional do silêncio, chamando a atenção ainda que, perante o delegado de polícia, o réu nada confessou. Assim, a prova da traficância é frágil, motivo pelo qual deve prevalecer a situação mais favorável, que no caso é a desclassificação da conduta do acusado para a prevista no art. 28, da Lei de Drogas. Por fim, caso o entendimento de Vossa Excelência seja pela condenação da pessoa acusada, a Defensoria Pública pugna pela fixação da pena-base no mínimo

legal, posto que não houve apreensão de quantidade expressiva de substância entorpecente. Já na terceira etapa, requer-se a aplicação da causa redutora de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que não há provas de que o réu é integrante de organização ou associação criminosa, o que fica demonstrado pela ínfima quantidade de droga apreendida. Além disso, trata-se de pessoa absolutamente primária. Ainda que ostente passagens na Vara da Infância, essas anotações não podem prejudica-lo, sob pena de violação ao artigo 228, da Constituição Federal. Além disso, recentemente a Sexta Turma do STJ já entendeu pela possibilidade da minorante em caso análogo, também envolvendo a pequena quantidade de substância entorpecente: "RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE AS DEMANDAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO 1. Não há violação do art. 619 do CPP quando verificado que o Tribunal de origem, embora sucintamente, examinou, de maneira clara, expressa e devidamente fundamentada, os motivos pelos quais, em sua visão, deveria ser aplicado o redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 2. Para a aplicação da minorante prevista no art.

33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 3. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Na ocasião, prevaleceu o entendimento intermediário de que "[...] o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração." 4. No caso, não obstante: a) o ato infracional praticado pelo ora recorrido, enquanto ainda adolescente, haja sido grave; b) o registro infracional estivesse devidamente documentado nos autos principais (de sorte a não pairarem dúvidas sobre o reconhecimento judicial de sua ocorrência); c) haja sido relativamente pequena a distância temporal entre o ato infracional e o crime objeto deste recurso (o qual foi perpetrado quando o réu tinha apenas 18 anos de idade); d) o ato infracional haja sido também por tráfico de drogas, certo é que o fato de haver a existência de um único registro em desfavor do acusado, por conduta praticada dentro de sua própria residência, não evidencia, por si só, que ele se dedica, com certa frequência e anterioridade, ao narcotráfico, em especial porque verificado que a quantidade de drogas apreendidas não foi excessivamente elevada e que, no contexto da prisão em flagrante, não foram apreendidos outros apetrechos destinados à traficância (tais como armamentos, balança de precisão ou anotações acerca da contabilidade do tráfico de drogas). 5. No acórdão apontado como paradigma, o réu ostentava mais de 10 registros anteriores por atos infracionais (estupro, roubo, furto, receptação, lesões corporais, ameaça, tentativa de homicídio e delitos de trânsito), de maneira que, por ausência de similitude fática entre as demandas, não há como se conhecer do recurso especial no tocante à alínea "c" do permissivo constitucional 6. Recurso especial parcialmente conhecido (somente em relação à alínea "a" do art. 105, III, da CF) e, nessa extensão, não provido". (REsp n. 1.827.202/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022.) Assim, a pena deve ser reduzida no patamar máximo, fixando-se, por consequência o regime inicial aberto. Presentes os requisitos legais, deve ainda a pena privativa de liberdade ser substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal.

não aplicada a minorante, requer-se a fixação do regime intermediário para o cumprimento da pena.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

PATRICK FERNANDO MAGDALENO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 01 de maio de 2022, por volta das 10,42 horas, na Rua Jamaica nº 29, Bairro Agua Branca, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 4,3g de cocaína, distribuídos em 32 "eppendorfs", substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, o qual é conhecido como ponto de tráfico, ocasião em que visualizaram o acusado, o qual, ao notar a presença da viatura, agiu de maneira suspeita e tentou se evadir. Em razão disso, abordaram-no e localizaram em sua posse 02 "eppendorfs" de cocaína e a quantia de R\$55,00, produto do narcotráfico. Em seguida, realizaram buscas nas proximidades e encontraram mais 30 "eppendorfs", idênticos àqueles encontrados em sua posse, pertencentes a ele e que se destinavam ao narcotráfico. O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 114). Defesa preliminar apresentada às fls. 118/123. Após, a denúncia foi recebida (fls. 131) e o réu foi citado (fls. 158).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade.

A Defesa pleiteou a absolvição, sustentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06 e, em caso de condenação por tráfico, o reconhecimento do privilégio.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) Boletim de ocorrência de fls. 07/09;
- 2) Auto de exibição e apreensão de fls. 11 e fotografia de fls. 12;
- 3) Laudo de constatação preliminar de fls. 14/16 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 105/107, os quais atestaram resultado positivo para cocaína em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 04), o réu negou o crime. Disse que estava no local dos fatos, pois havia comprado drogas, sendo 03 porções de cocaína, pelas quais pagou R\$ 20,00 cada. Alegou que não conhecia o traficante que lhe vendeu o entorpecente. Quando foi abordado pelos policiais militares, jogou os pinos no chão. Afirmou que a droga adquirida era destinada a seu consumo e que não confessou aos agentes que estava traficando nem apontou local em que guardava entorpecentes, dizendo, ainda, que desconhecia as demais drogas apresentadas na delegacia de polícia.

Interrogado em juízo (gravação), o acusado novamente negou o tráfico. Disse que foi local dos fatos para comprar drogas. Estava com 3 pinos de cocaína, pelos quais pagou R\$ 20,00, e ainda portava R\$ 50,00 em dinheiro. Logo após, foi abordado pelos policiais e PM Gustavo disse que "estava lhe devendo uma" porque já o havia abordado em data anterior por um furto. Afirmou que o traficante correu quando viu a aproximação da polícia. Não indicou aos policiais onde estavam escondidos os demais entorpecentes apreendidos.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 02) e em juízo (gravação), o policial militar João Guilherme Andrioli declarou que estavam em patrulhamento pelo bairro

Água Branca e, quando passaram pelo local dos fatos, o qual já era conhecido pelo ponto de tráfico de drogas, avistaram um indivíduo com camiseta branca e bermuda colorida, o qual, ao ver a viatura policial, imediatamente mudou de direção. Diante da atitude suspeita, resolveram abordá-lo, momento em que ele tentou se evadir em direção a uma praça, acelerando o passo. Alcançaram-no e, na posse dele, no bolso de sua roupa, encontraram 02 "ependorfs" de cor verde, contendo cocaína, R\$ 55,00 e 01 telefone celular. Questionado acerca dos fatos, o réu confessou, informalmente, que estava vendendo drogas e apontou o local onde guardava o restante dos entorpecentes. Assim, foram até o local apontado, uma árvore, distante de 10 a 15 metros do ponto inicial onde viram o réu, e encontraram o restante das drogas, as quais estavam embaladas de forma idêntica às que estavam com ele. Não conhecia o réu anteriormente. Não havia mais ninguém nas proximidades do esconderijo das drogas e do ponto de tráfico.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 03) pelo policial militar Gustavo Phatricy Nicolau Silva, o qual explicou que, inicialmente, quando entraram com a viatura na rua, o réu estava parado no ponto de tráfico e, ao notar sua presença, ele saiu caminhando. Quando fizeram a volta e o réu percebeu que estavam se aproximando dele, mudou de direção, tentando se evadir em direção a uma praça. Disse que já conhecia o réu anteriormente de uma abordagem de furto. Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Confirmam-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressaltados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos policiais militares: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desse quadro, não há dúvidas da prática delitiva pelo acusado nem se pode falar em ilicitude da ação dos policiais sob o argumento de fizeram a abordagem sem justas causa.

De fato, os policiais abordaram o réu em situação típica de flagrante de tráfico de drogas, eis que o viram em conhecido ponto onde se realiza o comércio ilegal e ele esboçou nítida intenção de fugir da polícia e de eventual abordagem quando percebeu que a viatura estava se aproximando, o que, aliado ao fato de não haver outras pessoas no ponto de tráfico, indicava que ele realizava a venda de drogas no local e, portanto, estava em situação de flagrante do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, o qual é considerado crime permanente, bastando, para sua configuração, que o agente traga consigo, guarde ou mantenha em depósito substância entorpecente para fins de tráfico, como ocorreu no caso dos autos.

Comprovado, outrossim, que o réu trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 32 "eppendorfs" contendo cocaína, substância esta que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De fato, sua negativa foi afastada pelos uníssonos e convergentes depoimentos dos policiais no sentido de que, parte da droga foi encontrada em sua posse e outra parte num esconderijo que ele próprio indicou. Todas as drogas estavam embaladas de forma idêntica, o que, aliado às demais circunstâncias da diligência policial e ao fato de não haver nenhuma outra pessoa suspeita nas proximidades, indica que todas lhe pertenciam.

Com efeito, ao perceber a presença da polícia no local, o acusado, que, inicialmente, estava parado no ponto de tráfico, saiu do local e, notar a maior aproximação dos agentes, mudou a direção em que estava caminhando e apressou o passo em direção a uma praça, tentando se evadir.

Não estivesse praticando o ilícito penal que lhe foi imputado e o qual, informalmente, confessou aos policiais, certamente não teria agido dessa forma. Ele próprio, no calor da abordagem, além de ter admitido que estava traficando, apontou aos agentes do Estado onde escondia o restante das drogas, em uma árvore

próxima a ele, o que permitiu seu encontro e apreensão.

Outrossim, com o réu foi apreendido dinheiro, totalizando R\$ 55,00, cuja origem lícita não foi comprovada e, no contexto, certamente, era produto do ilícito penal. Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.” (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

“MATERIALIDADE – Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA – Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em houve apreensão de drogas em poder do menor – Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' – Validade – Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO – Destinação a terceiros – Quantidade incomum com a figura do usuário – Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo – Apreensão de dinheiro – Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal – Denúncia – De rigor a condenação da ré – Absolução – Impossibilidade – Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO – Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral – Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA – Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal – natureza da droga de alto potencial lesivo – Manutenção – Presente a atenuante da menoridade – Redução da pena ao mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente – Exasperação da pena em 1/6 – Reconhecido o redutor na fração de 2/3 – Manutenção ante a inércia ministerial – Dedicção da ré à atividade criminosa – Passagem por ato infracional – Apreensão de considerável quantidade de droga – Profissionalização – Dedicção à atividade criminosa – Manutenção porque vedado a reformatio in pejus – Redução da pena – Impossibilidade – Improvimento ao apelo. REGIME – Fechado – Apreensão de elevada quantidade de droga – Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo – Alta reprovabilidade e periculosidade – Ré que ostenta processo por ato infracional – O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) – Regime fechado – Necessidade – Improvimento ao apelo”. (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

Não obstante responda a outro processo por furto qualificado, o réu deve ser considerado primário e de bons antecedentes, pois ainda não sofreu condenação criminal definitiva (cf. F.A. de fls. 77/79 e certidão de fls. 34/35).

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis. A quantidade de drogas, embora mais expressiva a ponto de indicar o tráfico, não

fugiu à normalidade da espécie.

Assim, aplico-lhe as penas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Não há agravantes.

Circunstâncias atenuantes, como a menoridade relativa e a confissão, não autorizam a redução das penas aquém do mínimo legal.

Inexistem causas de aumento.

Não estão presentes os requisitos do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o réu, embora primário, possui diversas passagens na Vara da Infância e Juventude com condenações pela mesma prática delitiva (cf. certidão de fls. 97 c.c. fls. 159/162 proc. 0016542-11.2017.8.26.0451 - fls. 80, furto - extinto; proc. 0017622-10.2017.8.26.0451 - fls. 93 c.c. 88 - receptação; execução n. 0014901-92.2018.8.26.0114 - fls. 88 - extinta; fls. 95/96 c.c. fls. 91: tráfico proc. n. 1501206-60.2019.8.26.0599 - extinta; fls. 100 - tráfico, proc. n. 0001027-33.2017.8.26.0451, apensado ao 13084-20.2016 - fls. 84 liberdade assistida, c.c. fls. 103- extinta; proc. nº 1500815-71.2020 em que lhe foi aplicada a medida socioeducativa de internação), o que demonstra que vem se dedicando a esta atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida.

Tal fato demonstra que o réu tem total desprezo pela lei e pela justiça e, mesmo depois que atingiu a maioridade penal, continuou traficando.

Trata-se, portanto, de traficante que vem reiterando nas atividades criminosas, não se podendo equipará-lo aos pequenos e eventuais traficantes.

Registro que a aplicação da minorante exige a existência cumulativa dos quatro requisitos presentes no dispositivo supramencionado, quais sejam: a) agente ser primário; b) possuir bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.

Conforme exposto acima, o réu não preencheu todos esses requisitos, tendo se dedicado às atividades criminosas desde a adolescência.

No sentido de que, em casos como esse, é incabível o privilégio, já se manifestaram as duas turmas do C. STJ:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N.11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. PATAMAR DE ELEVACÃO. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 3. Assentado pela instância antecedente que o paciente se dedica a atividade delitiva, uma vez que possui medidas socioeducativas em fase de execução, inclusive pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, a modificação desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para se afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 5. Segundo posicionamento deste Tribunal Superior, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades. 6. Concluído pelas instâncias ordinárias, com fundamento nas provas colhidas nos autos, que a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes

ocorreu nas proximidades dos locais previstos no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, a pretensão de afastá-la demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ, que dispõe: "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". (Precedentes). 8. Hipótese em que o Tribunal de origem majorou a pena na fração de 1/5, tão somente pelo fato de terem sido reconhecidas 2 majorantes (art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006), impondo-se, portanto, o redimensionamento para a percentual mínimo (1/6). 9. Fixada a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, sendo primário o réu e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o adequado e suficiente para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. 10. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 11. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a fração das majorantes para 1/6, ficando a reprimenda em 5 anos e 10 meses de reclusão, bem como para fixar o regime inicial semiaberto." (HC 529.996/SP, Quinta Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 12/11/2019). g.n.

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06). NÃO APLICAÇÃO. PASSAGENS ENQUANTO MENOR. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO DO PACIENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. PENA TOTAL SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. GRAVIDADE ABSTRATA E HEDIONDEZ DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO ELEVADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO PREJUDICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para não aplicá-la ao caso concreto em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, evidenciada sobretudo pelo fato do paciente ostentar passagens anteriores enquanto menor de idade, está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça. Ademais, para se acolher a tese de que o paciente não se dedica à atividade criminosa, é necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em habeas corpus. 3. É pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo, de acordo com o disposto no enunciado n. 440 da Súmula desta Corte e os enunciados ns. 718 e 719 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal - STF. 4. Sedimentou-se, ainda, o entendimento segundo o qual, nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2º, do Código Penal em conjunto com o art. 42 da Lei 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga. In casu, resta evidenciado o constrangimento ilegal na imposição do regime fechado pelas instâncias ordinárias, pois, a fixação foi em razão da hediondez e da gravidade abstrata do delito, o que vai de encontro com a jurisprudência desta Corte Superior, mormente se considerarmos que a quantidade de droga apreendida não foi elevada (uma porção de maconha com peso de 39,16g). Dessa forma, considerando, ainda, que o paciente é primário, bem como o quantum de pena aplicado (5 anos de reclusão), correta a

fixação do regime semiaberto, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 5. Mantida a pena fixada pelas instâncias ordinárias superior a 4 anos, o pleito quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra-se prejudicado, haja vista que o paciente não preenche os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento inicial da pena do paciente". (HC 512.197/SP, Quinta Turma, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. 06/08/2019).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. 1. Diz o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que a pena pode ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o paciente seja primário, portador de bons antecedentes, não integre organização criminosa nem se dedique a tais atividades. 2. As instâncias ordinárias afastaram, fundamentadamente, a incidência da benesse pretendida sob o fundamento de que as circunstâncias que ladearam a prática delitiva evidenciam a dedicação do paciente à atividade criminosa. 3. Destacou a sentença que o paciente, além de haver sido preso com considerável quantidade de cocaína - 35 (trinta e cinco) invólucros plásticos - em conhecido ponto de venda de entorpecentes, fazia "do crime seu meio de vida", não comprovando o exercício de qualquer atividade lícita e já ostentando registro anterior na Vara da Infância e Juventude por ato infracional equiparado a tráfico de drogas. 4. Indeferida a aplicação do redutor de pena com base em motivação idônea, inviável se torna, na via do writ, o revolvimento de provas com o fim de verificar a justiça da decisão. 5. O regime semiaberto é o recomendável, já que a pena-base foi fixada no mínimo legal, o paciente é primário, e a reprimenda não ultrapassa o patamar de oito anos (Súmula nº 440 do STJ). 6. Ordem parcialmente concedida". (HC 212.704/SP, Sexta Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, j. em 15/09/2011). Incabível, assim, o privilégio.

Quanto ao regime de pena, rendendo-me ao posicionamento das duas Turmas do C. STJ, conforme julgados supracitados, deixo de fixar o fechado, como vinha fazendo, para eleger o semiaberto, eis que a quantidade de droga, embora expressiva a ponto de revelar o tráfico, não é, por si só, indicativa de crime de maior relevância. No entanto, a pena é superior a quatro anos e